



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheiro Robson Marinho
Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**
Sessão **23/10/2024**
Exame Prévio de Edital – **Julgamento**

M-001: TC-018019.989.24-3
Representante: Laís de Oliveira
Representada: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Responsável: Miriam Carrasco Benites da Silva, Secretária Municipal de Mobilidade Urbana.
Assunto: Edital da Concorrência nº 2/24, do tipo maior oferta, cujo objeto é a outorga de concessão onerosa para exploração, administração, manutenção, obras complementares, limpeza, conservação e vigilância do Terminal Rodoviário Urbano Central e do Terminal Rodoviário Urbano Estudantes.
Valor Total Estimado: R\$ 17.923.878,26.
Advogados cadastrados no e-TCESP: Leandro Matsumota (OAB/SP 229.491) e Dalciani Felizardo (OAB/SP 299.287).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. CONCORRÊNCIA. OUTORGA DE CONCESSÃO ONEROSA. EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA DO OBJETO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RETIFICAÇÃO DETERMINADA. RECOMENDAÇÃO.

1. Por ser determinação do art. 18, § 1º, V, da Lei 14.133/2021, o tópico do levantamento de mercado do Estudo Técnico Preliminar – ETP deve evidenciar o problema a ser resolvido com a contratação, as alternativas possíveis para a solução desse problema e as justificativas para a escolha do tipo de solução a ser adotada.

2. Em licitação para a concessão onerosa da exploração de terminal rodoviário, a exigência de qualificação técnica deve conter as parcelas de maior relevância do objeto, nos termos do § 1º do art. 67 da Lei 14.133/2021 e dos postulados do julgamento objetivo e da transparência.

Trata-se de representação intentada por Laís de Oliveira contra o edital da Concorrência nº 2/24 da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, do tipo maior oferta, cujo objeto é a outorga de concessão onerosa para exploração,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

administração, manutenção, obras complementares, limpeza, conservação e vigilância do Terminal Rodoviário Urbano Central e do Terminal Rodoviário Urbano Estudantes.

Consoante o preâmbulo do edital, o procedimento licitatório é processado “*nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Federal nº 8.987/1995, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Municipal nº 7.911/2023, dos Decretos Municipais nºs: 17.500/2018, 22.144/2023, 22.435/2024 e 22.449/2024*”.

Insurgiu-se a Representante, numa apertada síntese, contra o seguinte:

(a) no tópico “3. Requisitos da Contratação” do Estudo Técnico Preliminar – ETP, o agente público não justificou “*a exigência legal in totum*”, descumprindo o regulamento local relacionado à matéria – Decreto Municipal nº 22.435/2024 -;

(b) nos itens “5. Levantamento de Mercado” e “6. Estimativa do Preço da Contratação” do Estudo Técnico Preliminar, estão sendo remetidos tais itens ao Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, de maneira que não está demonstrado levantamento de mercado para se saber qual das opções apresentadas se encontra a mais adequada para a solução do problema, descumprindo-se o art. 29 do Decreto Municipal nº 22.435/2024;

(c) o item 8.12.2¹ do edital não define as parcelas de maior relevância para a aferição da qualificação técnica, nos termos do art. 67, § 1º, da Lei 14.133/2021.

¹ “8.12.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade, por intermédio de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado emitido(s) em papel timbrado, comprovando-se que a licitante já tenha prestado, satisfatoriamente, serviços compatíveis com o objeto desta licitação, com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento);”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Nesses termos, requereu a suspensão cautelar do certame e a retificação do ato convocatório. O edital é datado de 10/7/2024 e a sessão pública estava designada para a data de 5/9/2024.

Considerando o tempo que ainda remanesce até a data designada para a sessão pública, a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes foi previamente notificada para tomar conhecimento dos termos da representação e apresentar as alegações julgadas pertinentes.

Justificativas foram encartadas pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes no evento 29.

Numa breve síntese, salientou não haver que se falar em inobservância à legislação pertinente e muito menos em falta de estudos ou levantamento de mercado.

Aduziu que o Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira a que faz remissão o Estudo Técnico Preliminar apresentou pormenorizadamente todos os elementos necessários para a conclusão de que a melhor opção adotada pela Municipalidade seria pela concessão, baseando-se inclusive em casos concretos e contratos do próprio Município.

Destacou que o referido documento detalha as receitas, despesas e investimentos projetados, pautando-se pelas demandas do Município e pela perspectiva de atratividade do mercado para futuros investidores, tornando o processo transparente e eficaz tanto para o interesse público quanto para a iniciativa privada.

Ponderou ser importante observar que se trata de um contrato de concessão, onde se entende que, pela sua própria natureza, traz em si algum grau de risco natural ao interessado, de maneira disse entender suficientes as informações prestadas no ato convocatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Quanto à definição das parcelas de maior relevância para a aferição da qualificação técnica, alegou que: *“a exigência de 50% (cinquenta por cento) é perfeitamente exigível, conforme § 2º do artigo 67 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, especialmente porque não há limitação de tempo e de locais específicos relativos aos atestados”*.

Porque não se mostrava suficiente a justificativa para a não definição das parcelas de maior relevância na aferição da qualificação técnica é que, por decisão do e. Tribunal Pleno em sessão de 4/9/2024, foi requisitada cópia do edital para o exame nos termos dos arts. 170, § 4º, e 171, §§ 1º e 3º da Lei Federal nº 14.133/21, bem como foi determinada a sustação cautelar do certame licitatório e fixado prazo de 10 (dez) dias para cumprimento e apresentação de justificativas e esclarecimentos.

Desta feita não foram apresentadas novas justificativas pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

A Assessoria Técnica manifestou-se pela procedência, enquanto a Chefia da Assessoria Técnica manifestou-se pela procedência parcial.

O Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência.

É o relato do necessário.

npg



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Voto

TC-018019.989.24-3

Circunscrito aos termos da peça inicial, a representação é parcialmente procedente, nos moldes do parecer da Chefia de Assessoria Técnica.

De início, há as impugnações contra 3 itens do Estudo Técnico Preliminar – ETP.

No que diz respeito à impugnação contra o item “5” do Estudo Técnico Preliminar, relativo ao “levantamento de mercado”, ela é procedente diante de sua desconformidade com o art. 18, § 1º, V, da Lei 14.133/2021², porquanto os elementos demandados pelo texto legal dizem respeito ao problema a ser resolvido pela contratação, às alternativas existentes no mercado para a solução desse suscitado problema e à justificativa técnica e econômica para a solução escolhida pela Administração, e nenhum desses elementos constam do ETP em análise.

Veja que o item “5” do ETP³ apenas se reporta ao Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, de sorte que deve ser retificado o item “5” do ETP, no mínimo, para dar transparência ao planejamento e ao processo de decisão do administrador no caso em tela, que é o que é demandado pelo legislador federal no dispositivo em apreço.

² “**Art. 18** [...] **§ 1º** O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do *caput* deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: [...] V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;” (sublinhado acrescido).

³ “**5. Levantamento de Mercado** (inc. V, § 1º, art. 18).

5.1. Faz parte do edital, como anexo, o Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, onde encontram-se detalhados todos os quantitativos previstos de receita bruta e despesas do Contrato de Concessão.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Deverá a Administração, pois, retificar o item “5” do Estudo Técnico Preliminar – ETP, relativo ao levantamento de mercado nos termos do art. 18, § 1º, V, da Lei 14.133/2021, a fim de que nele passe a constar o problema a ser revolido com a contratação, as alternativas possíveis para a solução desse problema e as devidas justificativas para a escolha do tipo de solução a ser adotada.

Já no que tange à impugnação contra o item “6” do ETP, relativo à estimativa do preço da contratação nos termos do art. 18, § 1º, VI, da Lei 14.133/2021, não vislumbro retificação a ser determinada por conta do fato desse item se reportar ao Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira.

É que não se trata de um contrato de compra ou do ajuste de uma prestação de serviços continuados, mas, de um contrato de concessão onerosa, cuja complexidade não se solve por uma simples pesquisa de preços, mas, por um levantamento mais sofisticado de receitas e despesas estimadas que irão resultar justamente no aludido Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira.

Do que é possível numa análise sumária e de cognição não plena, inerente ao rito do exame prévio do edital, pode ser observado que o Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, a que se reporta o item 6 do ETP e que aqui consta do evento 1.9, contempla os resultados dos levantamentos e indica estimativas de receitas, fluxos de caixa com valor presente líquido, taxa interna de retorno e tempo de *payback*, bem como despesas operacionais (OPEX) e investimentos (CAPEX) orçados com base na tabela SIURB.

Se há ou não consistência nos dados lançados nesse aludido Estudo, é questão que escapa ao rito do exame prévio de edital.

Frente a tal cenário, e ao menos neste rito sumário e excepcional, não vislumbro nada a ser retificado no item “6” do ETP, relativo à estimativa do



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

valor da contratação, pelo fato de o item se reportar ao Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira.

E por fim há a queixa contra o item “requisitos da contratação” do ETP, ligado ao art. 18, § 1º, III, da Lei 14.133/2021. A esse respeito, observa Marçal Justen Filho que “*a terminologia legal é imprecisa*”, entretanto, deve-se entender que esses requisitos da contratação “*consistem nas exigências de diversa ordem a serem atendidas para a produção da contratação*”⁴. Em outras palavras, requisitos da contratação não dizem respeito a condições para a participação no certame licitatório, tais como as cláusulas habilitatórias, mas, trata-se de condições para a execução e consecução do objeto a ser contratado.

Nesse cenário, sobre a impugnação onde a Representante suscita a não adoção dos dispositivos do art. 29, III⁵, do Decreto Municipal nº 22.435/2024, entendo que a queixa procede somente em parte, na medida em que o § 3º⁶ deste mesmo art. 29 do Decreto Municipal estabelece que esse inc. III não é tópico obrigatório do ETP, tal como faz o § 2º do art. 18 da Lei 14.133/2021, fixando apenas o dever de a Administração consignar as devidas justificativas da não adoção dos elementos desse inc. III.

Portanto, determino apenas que a Prefeitura de Mogi das Cruzes consigne no item “3” do Estudo Técnico Preliminar as devidas justificativas para

⁴ Justen Filho, Marçal, *Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas*, Editora Revista dos Tribunais, 2021, Pg. 357.

⁵ “**Art. 29** - O Estudo Técnico Preliminar (ETP) conterá os seguintes elementos: [...] **III** - descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução entre aqueles disponíveis para o atendimento da necessidade pública, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, descrevendo: **a)** requisitos do negócio para a contratação; **b)** requisito de capacitação de agentes públicos para licitar ou fiscalizar o cumprimento do objeto do futuro contrato; **c)** requisitos legais, observando a legislação aplicável ao objeto; **d)** requisitos de manutenção, destacando a forma e equipe técnica; **e)** requisitos temporais, destacando o prazo máximo que objeto deverá ser entregue ou concluído; **f)** requisitos de segurança, destacando as responsabilidades da contratada; **g)** requisitos sociais, ambientais e culturais, quando as contratações devem observar os critérios de sustentabilidade de acordo com as contratações sustentáveis; **h)** requisitos de segurança do trabalho, obediência às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas aplicáveis.”

⁶ “**Art. 29** [...] **§ 3º** O ETP deve obrigatoriamente conter os elementos dispostos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos descritos nos outros incisos do caput, apresentar as devidas justificativas no próprio documento.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

a não adoção de todos os elementos do inc. III do art. 29 do Decreto Municipal nº 22.435/2024, nos termos do § 3º desse art. 29.

Por fim, remanesce a procedência da impugnação dirigida contra o item 8.12.2⁷ do edital, pelo fato de não definir as parcelas de maior relevância para a aferição da qualificação técnica, nos termos do art. 67, § 1º, da Lei 14.133/2021.

Veja que a Administração alegou tão somente que a requisição “[...] de 50% (cinquenta por cento) é perfeitamente exigível, conforme § 2º do artigo 14.133 de 1º de abril de 2021, especialmente porque não há limitação de tempo e de locais específicos relativos aos atestados [...]”.

Entretanto, tal linha de justificativa diz respeito tão somente ao aspecto do quantitativo mínimo, e a impugnação aqui intentada está a questionar a não estipulação de parcelas de maior relevância técnica nos moldes do § 1º do art. 67 da Lei 14.133/2021, e nesse aspecto específico entendo haver riscos ao certame.

É que ao estipular a experiência anterior em “*serviços compatíveis com o objeto desta licitação*”, parece-se, de um lado, haver o risco aparente de poder participar apenas quem já tenha anteriormente explorado a concessão de um terminal rodoviário, o que está em desconformidade com a Súmula nº 30 deste Tribunal; e de outro lado, se há a possibilidade de participar a partir da experiência em itens de relevância do objeto, há margem excessiva de discricionariedade à comissão de licitação para aferir o que é admissível ou não em sede de aptidão técnica, o que está em desconformidade com os postulados do julgamento objetivo e da transparência.

⁷ “8.12.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade, por intermédio de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado emitido(s) em papel timbrado, comprovando-se que a licitante já tenha prestado, satisfatoriamente, serviços compatíveis com o objeto desta licitação, com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento);”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Como observado pela Assessoria Técnica, o Termo de Referência abarca a execução de serviços nos Terminais Rodoviários Urbanos de (i) administração, (ii) manutenção, (iii) obras complementares de infraestrutura e ampliação, (iv) limpeza, (v) conservação e (vi) vigilância, de maneira que não há certeza quanto aos específicos serviços ou atividades sobre os quais recairiam a demanda por comprovação de experiência anterior, e tampouco são indicados os aspectos dos serviços sobre os quais seria efetivamente aplicado o percentual de 50%.

Tal nível de insegurança jurídica é incompatível com o torneio licitatório que busca investimentos numa concessão de dois terminais rodoviários urbanos, razão pela qual deverá ser retificado o item 8.12.2 do edital para nele ser inseridas as parcelas de maior relevância do objeto nos termos do art. 67, § 1º, da Lei 14.133/2021.

Por fim, e pela relevância do tema, consigno a recomendação proposta pelo Ministério Público de Contas acerca do Plano de Contratações Anual - PCA, nos seguintes termos:

“[...] A Municipalidade de Mogi das Cruzes reconhece a relevância do referido instrumento de planejamento, tanto é que, no Decreto Municipal n. 22.435, de 3 de janeiro de 2024, prescreve que os estudos técnicos preliminares precisam estar alinhados com o PCA⁸. Em acréscimo, o item 2 do ETP sob exame carrega o título: ‘ALINHAMENTO COM O PCA (inciso II, § 1º, art. 18)’.

A despeito disso, no site de Mogi das Cruzes e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP⁹), não constam os planos deste e do ano seguinte. Em vista disso, e dada a proximidade de encerramento do presente ano, cabe recomendação para que Mogi das Cruzes elabore, o quanto antes, o Plano de Contratações de 2025 e o disponibilize no

⁸ “Art. 29. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) conterá os seguintes elementos: [...] II - demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, bem como identificação da previsão no Plano de Contratação Anual de (PCA), ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão neste plano;” (disponível em <https://leismunicipais.com.br/a/sp/m/mogi-das-cruzes/decreto/2024/2244/22435/decreto-n-22435-2024-proc-n-11750-2023-1doc> – acessado em 04/10/2024).

⁹ <https://pncp.gov.br/app/pca?pagina=1>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

PNCP, em atenção ao Comunicado SDG nº 12/2023¹⁰, de 15/03/2023, e Comunicado SDG nº 34/2023¹¹, de 15/06/2023, e à sua legislação local [...].”

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** da representação, com **determinação à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes** para que retifique o ato convocatório:

(i) no item “5” do Estudo Técnico Preliminar – ETP, relativo ao levantamento de mercado nos termos do art. 18, § 1º, V, da Lei 14.133/2021, a fim de que nele passe a constar o problema a ser revolido com a contratação, as alternativas possíveis para a solução desse problema e as devidas justificativas para a escolha do tipo de solução a ser adotada;

(ii) no item “3” do Estudo Técnico Preliminar - ETP, ligado aos requisitos da contratação nos termos do art. 18, § 1º, III, da Lei 14.133/2021, a fim de que nele passe a constar as devidas justificativas para a não adoção de todos os elementos do inc. III do art. 29 do Decreto Municipal nº 22.435/2024, nos termos do § 3º desse art. 29; e

(iii) no item 8.12.2 do edital para nele ser inseridas as parcelas de maior relevância do objeto nos termos do art. 67, § 1º, da Lei 14.133/2021.

Deverá a Administração republicar o edital retificado e reabrir o prazo para oferecimento das propostas nos termos do § 1º do art. 55 da Lei 14.133/2021, cessando-se desde já os efeitos da medida cautelar inicialmente decretada.

Acolhido este entendimento pelo e. Plenário, deverá ser intimada a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, na forma regimental.

¹⁰ <https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/plano-contratacoes-anual>

¹¹ <https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/aplicacao-lei-federal-ndeq-1413321>